

1500665-22.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... tinha maconha para vender. Disse-lhe que não fazia tráfico e o avisou da aproximação da polícia. O local era conhecido como ponto de tráfico. O réu ficou "meio assustado" e fugiu com a moto. Não viu se o réu tinha alguma pochete. Afirmou que poucos dias antes dos fatos foi apreendido por ato infracional de tráfico de drogas. No momento dos fatos, os familiares do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13419-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500665-22.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500665-22.2022.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2123106/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2123106/2022 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEYNILDO CHRISTIAN PEREIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira

Vistos,

LEYNILDO CHRISTIAN PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 5 de maio de 2022, por volta das 20 horas e 30 minutos, na rua Fernando Monteiro, bairro Cecap, nesta cidade e comarca, trazia consigo e transportou na motocicleta Honda CG 150 de placa DOV3G85, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 22 eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 35,51g; e 52 porções de cocaína, na forma de pedras de "crack", com peso bruto aproximado de 17,9g (cf. laudo de constatação de fls. 31/36, fotografia das drogas de fls.13, boletim de ocorrência de fls. 7/9 e AEA de fls.

11), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares patrulhavam pelo lugar indicado, conhecido ponto de tráfico de drogas, quando visualizaram o acusado interagindo com um transeunte. Ao perceber a presença da patrulha, Leynildo empreendeu fuga com sua motocicleta. O acusado foi perseguido pelos PMs e finalmente alcançado.

Submetido à busca pessoal, verificou-se que ele trazia consigo, numa bolsa, 22 eppendorfs contendo cocaína e 52 pedras de "crack", bem como R\$ 330,00 provenientes do comércio de drogas.

Conclui a denúncia que a quantidade de drogas revelou sua destinação ao consumo de terceiros.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 118). Defesa preliminar apresentada às fls. 127/138. Após, a denúncia foi recebida (fls. 144/145) e o réu foi citado às fls. 192.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e três arroladas pela defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade do delito.

A Defesa pediu a conversão do julgamento em diligência para produção de prova, arguiu ilicitude da ação dos policiais e, no mérito, requereu a absolvição por falta de provas.

É o relatório.

Decido.

Primeiramente, indefiro o pedido da Defesa de conversão do julgamento em diligência para que possa ter acesso ao processo ao qual respondeu a testemunha Kauan, arrolada pela defesa, na Vara da Infância e da Juventude.

Tal prova não é imprescindível ao deslinde da questão porque não guarda relação com o caso dos autos e, não obstante as alegações do d. representante do Ministério Público, não servirá como elemento de convicção para se afastar a credibilidade do testemunho dessa pessoa.

Afasto, outrossim, a preliminar de ilicitude da ação dos policiais.

Conforme se verá a seguir, com a análise das provas produzidas, o réu foi flagrado em via pública agindo de forma suspeita, indicativa da prática do comércio ilegal de entorpecentes.

De fato, ele foi visto parado em ponto de tráfico fazendo contato com um transeunte e, ao notar a aproximação da polícia, imediatamente, empreendeu fuga com uma motocicleta, o que confirmou a suspeita de que realizava o narcotráfico no local e permitiu o acompanhamento e ação dos policiais, com abordagem e busca pessoal, não se verificando qualquer ilicitude.

Registre-se que o tráfico de drogas é crime permanente e, havendo indícios de que o réu estava portando substância ilícitas para o comércio, não há qualquer razão para invalidar a sua abordagem e revista pessoal.

Em caso análogo, assim decidiu o C. STJ:

"A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R\$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região. (...)" (HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

No mérito, a denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 07/09, auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, fotografia de fls. 13, laudo de constatação de fls. 31/35 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 109/111, ambos com resultado positivo para cocaína em relação às substâncias apreendidas.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 09), o réu não quis se manifestar.

Interrogado em juízo (gravação), negou o tráfico, dizendo que não trazia consigo pochete nem drogas no dia dos fatos. Só possuía R\$ 150,00, dinheiro que recebeu da venda de reciclagem. Relatou que, no dia da ocorrência, passou na casa de sua prima e disse a ela que ia comprar fralda e leite para o filho. Viu o menor Kauan na rua e lhe perguntou se tinha maconha. Ele respondeu que não e falou para tomar cuidado porque os policiais estavam por perto. Quando passou pela avenida, viu os policiais abordando um rapaz que não era Kauan. Em seguida, eles liberaram o rapaz e foram atrás dele (o interrogando). Eles já haviam forjado o encontro de drogas com seu irmão. Assim, quando os viu, fugiu para que não fizessem injustiça com ele e também porque não era habilitado. Parou na avenida de sua casa, na frente de um bar. Quando viu sua prima, jogou a moto e a abraçou. Mesmo assim, os policiais o abordaram e o agrediram, bem assim a moça. Levaram-no para a delegacia. Achou que era porque tinha corrido com a moto. Lá soube que lhe imputaram um crime de tráfico de drogas. Eles apresentaram entorpecentes na delegacia. Afirmou que tinha saído da cadeia há um ano e passou a trabalhar com o primo, até que sofreu um acidente e precisou parar. Quando se recuperou, começou a trabalhar com reciclagem. Os vizinhos eram legais e guardavam reciclagem para ele. Disse que já conhecia o policial Zanoni porque ele atuou na prisão de seu irmão. Esse mesmo policial já o havia abordado quando era menor de idade, há um bom tempo. E, na maioridade, logo que saiu da cadeia, também foi abordado por esse policial junto com outro menino, Paulo Henrique Fernandes da Silva. Naquela ocasião, os policiais queriam que lhes desse um revólver ou a "casa de alguém". Ele levaram Paulo Henrique no meio do mato e o agrediram violentamente, inclusive nas partes íntimas, fazendo-o desmaiar. Naquele dia, eles o liberaram e levaram Paulo Henrique preso. Por fim, declarou que, após os fatos objeto deste processo, a mãe foi visitá-lo na cadeia e disse que os policiais entraram em sua casa várias vezes (4 ou 5 vezes) sem mandado.

A negativa foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 03) e sob o crivo do contraditório (gravação), o policial militar Flavio Zanoni Junior declarou que estava com seu colega da ROCAM em patrulhamento pelo bairro Cecap quando avistaram o acusado com uma motocicleta Honda CG 150 parado no local, conhecido como ponto de tráfico, conversando com um transeunte. Ao avistarem os policiais, os dois agiram de forma suspeita, tendo transeunte corrido a pé para um lado e o acusado empreendido fuga

na condução da motocicleta. Diante da atitude suspeita, seguiram o réu pelas ruas do bairro até que conseguiram abordá-lo, o que ocorreu numa via onde havia alguns parentes dele, onde ele parou a motocicleta. Esclareceu que, até ser abordado, ele passou diversas vezes nessa rua onde tais pessoas estavam aglomeradas (ele ia e voltava até o Delta, passando sempre pela rua onde estavam os parentes). Informou que, em revista pessoal, encontraram na posse do réu uma bolsinha contendo R\$ 330,00 em notas diversas, 52 porções de crack e 22 eppendorfs de cocaína. Esclareceu que não conhecia o réu anteriormente, mas já havia prendido o irmão dele com porções de cocaína e, se não estivesse enganado, também de crack. Informou, por fim, que não ingressaram na residência do réu.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 04) e em audiência (gravação) pelo policial militar Roger da Silva Olivencio Mendes, o qual acrescentou que, no momento da abordagem, o réu abraçou uma senhora que ali estava (acredita que era sua mãe), e que os parentes dele apenas falaram para não o agredirem, o que não realmente não fizeram. Disse que ele teve que ser algemado para evitar fuga e ser conduzido até o plantão. Foi necessário apoio de outra viatura, pois pessoas se aglomeraram na rua e a população daquele bairro costuma reagir mal à ação da polícia ali. Disse que tudo o que foi apreendido no local foi encaminhado à delegacia e lá o que a Autoridade Policial não apreende, devolve a algum familiar do preso. Não conhecia o réu ou seus familiares antes dos fatos. Fazia pouco tempo que patrulhava na região.

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

A alegação do réu de que sofria perseguição por parte do policial Zanoni está isolada no contexto probatório e, portanto, não pode ser acolhida para se afastar a força de seu testemunho, que, reitere-se, coincide com a do outro policial contra o qual o réu não teceu qualquer consideração desfavorável.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou

entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra de agente público: enquanto o interesse deste é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos agentes da polícia não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

Os documentos trazidos pela nobre Defesa às fls. 217/244 não guardam relação com o caso dos autos e versam sobre fatos envolvendo outros autuados.

Quanto aos depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa, as quais flagrantemente tentaram inocentar o acusado, não podem ser acolhidos sem reservas, porquanto elas foram bastante contraditórias em suas declarações, inclusive conflitando, em alguns pontos, com a versão do próprio réu.

Dessa forma, seus relatos não servem para afastar a força probante dos testemunhos policiais.

Vejam os:

Ricardo de Paula, em audiência (gravação), disse que presenciou a prisão do réu, pois estava num bar muito conhecido e frequentado pelos moradores do bairro ("Bar da Dode"). Estava sentado na frente do estabelecimento, do mesmo lado da avenida. Viu o réu se aproximando de moto e notou quando ele subiu num canteiro e soltou a motocicleta. A prima dele, que estava do outro lado da avenida na esquina conversando com uma amiga dela, saiu correndo ao encontro do réu. Ele levantou as mãos e ela se aproximou e o abraçou. Os policiais chegaram agredindo os dois. Eles enforcaram o réu e o jogaram no chão. A prima dele gritava para pararem. Depois chegaram outros policiais e mandaram todos saírem de perto. Não viu nenhuma pochete no corpo do réu. Conhece-o do bairro. Kauã estava do outro lado da rua no momento da abordagem. Não conversaram. Não tinha nenhum outro Ricardo no local. No dia dos fatos estava frio. O réu estava de calça de moletom azul e blusa azul. Antes dos fatos, a prima do réu passou no bar para ir ao mercado. Depois, ela voltou do mercado e ficou conversando com a amiga na esquina. Foi neste momento que os policiais chegaram. Isso ocorreu bem na frente do bar. A mercearia ficava a uns 25 metros de distância do bar. Por fim, informou que ficou a aproximadamente 50 metros do local da abordagem.

Entretanto, a prima do réu, Thaiara Andressa Moraes Pereira, declarou em juízo (gravação) que, no momento da abordagem do réu, estava saindo da mercearia e não que estava parada na esquina do bar conversando com uma amiga.

De fato, afirmou Thaiara que, no dia dos fatos, o réu chegou em sua casa de moto (explicou que ele morava com ela) e lhe disse que iria ao mercado comprar algumas coisas para o filho e já voltava para jantar. Como ele ia ao mercado com a mulher, com quem estava brigado, não pediu para ele comprar Coca-Cola. Assim, ela mesmo saiu para comprar a bebida na mercearia perto da avenida. Quando chegou na mercearia, viu os policiais com um menino, o qual não reconheceu. Entrou na mercearia, onde conversou com uma amiga e, assim que saiu, já viu o réu fugindo dos policiais. Ao vê-la, ele parou, pulou da moto e a abraçou. Os policiais se aproximaram de forma violenta e o separou dela. Agrediram-nos (eles puxaram seu cabelo e sua blusa e jogaram o réu no chão enforcando-o). Chegaram várias viaturas. Os policiais mandaram se afastar para não tomarem bala perdida. Ficou num canto. Quando o réu foi jogado no chão pelos policiais, aproximou-se para perguntar o que estava acontecendo. Quando chegou na delegacia, foi informada que o réu havia sido preso por tráfico de drogas. O réu estava de moletom azul, meia e chinelo. Ele não tinha pochete. Não sabe o motivo pelo qual o réu fugiu dos policiais. Já foi testemunha de defesa do réu em outro processo de tráfico no qual ele foi pego na sua residência. Depois que saiu da prisão, ele parou de traficar e passou a trabalhar "catando reciclagem". Com o dinheiro dessa atividade, o réu comprou a motocicleta. Os fatos ocorreram por volta das 19 horas.

Por fim, o menor Kauan Hyago Manoel Reis deu versão diferente das testemunhas e do próprio réu.

Com efeito, ouvido em juízo (gravação), presença de sua responsável legal, o adolescente declarou que conhecia o réu de vista, do bairro. Viu quando ele foi preso. No dia, os policiais o abordaram (o depoente) e, quando viram o réu passando de motocicleta, liberaram-no "do quadro" e foram atrás dele. Pegaram o réu e o agrediram com cassetetes. Contou que, antes de ser abordado, quando estava descendo a rua da mercearia e da padaria do Sr. Fábio, o réu se aproximou com a moto, fez contato com ele e lhe perguntou se tinha maconha para vender. Disse-lhe que não fazia tráfico e o avisou da aproximação da polícia. O local era conhecido como ponto de tráfico. O réu ficou "meio assustado" e fugiu com a moto. Não viu se o réu tinha alguma pochete. Afirmou que poucos dias antes dos fatos foi apreendido por ato infracional de tráfico de drogas. No momento dos fatos, os familiares do réu estavam no bar. Depois disse que não tinha certeza de que os familiares do réu

estavam naquele local. Não os conhecia. Seu amigo Ricardo, que estava no bar, comentou que iria encontrar o réu no bar. Policiais de várias viaturas atuaram na prisão do réu. Não esteve na delegacia.

Como se vê, há diversas contradições entre os relatos das testemunhas arroladas pela defesa, o que afasta completamente a força probante de seus testemunhos.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu trazia consigo e transportava, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 22 eppendorfs contendo cocaína e 52 pedras de "crack".

De fato, sua negativa foi afastada pelos uníssonos e convergentes depoimentos dos policiais militares no sentido de que as drogas estavam na sua posse.

Confirma a prática delitiva o fato de o réu ter agido de forma suspeita ao notar a aproximação dos policiais, empreendendo fuga na condução da motocicleta, o que ocorreu logo após ele ser flagrado parado em ponto de tráfico fazendo contato com um transeunte.

A situação em que o réu foi flagrado era típica do tráfico de drogas, o que se confirmou com o fato de ele empreender fuga, fato que permitiu o acompanhamento e ação dos policiais, com abordagem e busca pessoal, que resultou no encontro de drogas e dinheiro.

Registre-se que o destino mercantil dos entorpecentes apreendidos ficou evidenciado não só pelas circunstâncias da diligência, mas também em razão da quantidade de drogas, incompatível com a situação de mero usuário e pelo fato de estarem embaladas em porções individuais, como geralmente são comercializadas (fotografia de fls. 13).

Outrossim, com o réu foram apreendidos R\$ 330,00 em notas trocadas, cuja origem cuja origem lícita não foi comprovada, presumindo-se decorrer do tráfico que ele realizava.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS - Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO." (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20/07/2020). g.n.

"MATERIALIDADE - Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em que houve apreensão de drogas em poder do menor - Confirmação

pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' - Validade - Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - Destinação a terceiros - Quantidade incomum com a figura do usuário - Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo - Apreensão de dinheiro - Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal - Denúncia - De rigor a condenação da ré - Absolvição - Impossibilidade - Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO - Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral - Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA - Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - natureza da droga de alto potencial lesivo - Manutenção - Presente a atenuante da menoridade - Redução da pena ao mínimo legal - Súmula 231 do STJ - Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente - Exasperação da pena em 1/6 - Reconhecido o redutor na fração de 2/3 - Manutenção ante a inércia ministerial - Dedicção da ré à atividade criminosa - Passagem por ato infracional - Apreensão de considerável quantidade de droga - Profissionalização - Dedicção à atividade criminosa - Manutenção porque vedado a reformatio in pejus - Redução da pena - Impossibilidade - Improvimento ao apelo. REGIME - Fechado - Apreensão de elevada quantidade de droga - Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - Alta reprovabilidade e periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado - Necessidade - Improvimento ao apelo". (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Passo à individualização das penas.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

A diversidade de drogas e a quantidade, embora expressiva a ponto de indicar o tráfico, não fugiram à normalidade da espécie.

Assim, fixo as penas-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Não se fazem presentes circunstâncias atenuantes.

O réu é reincidente específico (fls. 105/106: condenado por tráfico no processo nº 1500798-69.2019.8.26.0599, da 2ª Vara Criminal local, cujo trânsito em julgado se deu aos 29/09/2020), o que enseja o aumento da reprimenda em 1/6, perfazendo cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de penas.

Registro que, por expressa disposição legal, a reincidência impede a aplicação do redutor do parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06 e, tratando-se, inclusive, de reincidência específica, impõe a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, sem possibilidade de substituição por restritivas de direitos ou concessão de sursis, pois indica que o réu vem reiterando na prática do crime em questão.

Acrescente-se a isso as graves consequências do delito de tráfico, que fomenta a prática de vários outros crimes, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que dificilmente conseguem se livrar do vício.

Eleição de regime diverso e aplicação de penas substitutivas da corporal no caso

concreto dos autos, as quais também são incompatíveis com a quantidade de pena aplicada, impediriam que a pena cumprisse suas funções de prevenção e reprovação do crime, pois não fariam com que o réu sentisse as consequências de seu grave ato.

Há várias decisões de nossos Tribunais no sentido de que é possível a eleição do regime fechado, sem substituição por restritivas de direitos, no crime de tráfico de drogas em casos semelhantes.

Confiram-se julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Pretensão à absolvição ou à desclassificação para porte de drogas visando consumo próprio. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas escorreitas. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes ostentados pelo réu. Réu reincidente. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Elementos concretos que demonstram a dedicação do réu às atividades criminosas. Regime fechado mantido. Recurso não provido." (TJSP - Apelação Criminal 1500011-19.2021.8.26.0551. 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa - j. 25/08/2022) - g.n.

"Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria do delito comprovadas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Pena-base fixada no mínimo legal. Incidência da agravante da reincidência. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Mantido o regime inicial fechado. Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos. Detração Penal deverá ser analisada pelo Juízo da Execução. Recurso desprovido." (TJSP - Apelação Criminal 1522206-94.2021.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Jucimara Esther de Lima Bueno - j. 24/08/2022) - g.n.

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRELIMINARES - Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva - Ilícitude da prova. Invasão de domicílio não configurada. Crime permanente e estado de flagrante. Fundada suspeita evidenciada - Rejeição. MÉRITO - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de quantidade considerável de droga (44 pedras de cocaína, sob a forma de crack, com massa líquida de 23,74 gramas; e 42 pinos de cocaína, com massa líquida de 0,68 gramas), além de dinheiro - Condenação mantida. PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO - Bases acima dos patamares. Personalidade negativa do agente afastada. Princípio do nemo tenetur se detegere - Reincidência específica (1/6) - Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Regime inicial fechado - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) - Apelo provido para reduzir as penas." (TJSP - Apelação Criminal 1500056-79.2022.8.26.0618. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz - j. 25/08/2022) - g.n.

"APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito objetivando a fixação da pena base no mínimo legal. 1. Materialidade comprovada pela apreensão das drogas e pelo exame químico-toxicológico. Autoria certa. Depoimento firme dos policiais civis indicando a detenção em flagrante do acusado, bem como a apreensão dos entorpecentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Réu confesso. 2. Dosimetria. 2.1. Afastamento em parte das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Quantidade e natureza da droga que não conferem maior reprovabilidade à conduta. 2.2. Caracterização de maus antecedentes e reincidência com base em condenações distintas. Bis in idem não violado. Inteligência da Súmula n. 241 do STJ. Redução do aumento aplicado na primeira fase para 1/6 2.2. Agravante da reincidência integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea. 2.3. Reincidência que impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado e que justifica a imposição de regime prisional mais severo, afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJSP - Apelação Criminal 1500254-35.2022.8.26.0548. 16ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli - j. 25/08/2022) - g.n.

Registro que, contrariamente ao que alega a nobre defesa, o reconhecimento da reincidência para fins de impedir a concessão de benefícios ao acusado e apená-lo de forma mais grave não fere a coisa julgada, nem constitui “bis in idem”, pois não se trata de punir o agente duas vezes pelo mesmo fato.

Como bem ensina Guilherme de Souza Nucci, essa ideia “peca pela simplicidade. O sistema de fixação de penas obedece a outro preceito constitucional, merecedor de integração com os demais princípios penais, que é a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF)” (CPComentado - RT, 13ª ed., pag. 464).

Ao se reconhecer a reincidência e aumentar a pena do crime em razão dessa agravante ou deixar de aplicar ao réu alguma benesse, o Estado nada mais faz do que punir com maior rigor o agente que, tonando a delinquir, desafia a ordem pública e as leis vigentes, demonstrando, no dizer do professor Nucci, “persistência e rebeldia inaceitáveis para quem pretenda viver em sociedade. Destarte, sofre uma punição mais severa” (obra citada, pag. 464).

Neste sentido já se pronunciou o C. STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTO VÁLIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 10 meses acima do mínimo legal com fundamento na quantidade do entorpecente apreendido - 82 caixas de tijolos de maconha (4.365,3 kg) - o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). 3. A reincidência do paciente foi validamente reconhecida, nos termos dos arts. 61, 63 e 64, I, do Código Penal, em razão de ostentar condenação anterior, não alcançada pelo período depurador, pela prática de crime patrimonial descrito no art. 180, caput, do Código Penal. 4. Tratando-se de réu reincidente, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. 5. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, ficam mantidos o regime fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de réu reincidente, nos termos dos arts. 33, § 2º, e 44, I e II, do Código Penal. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 687.003/SP. Quinta Turma. relator Ministro Ribeiro Dantas - j. 7/6/2022) - g.n.

No mesmo sentido a orientação do E. TJSP:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico. APELAÇÃO CRIMINAL - PENA E REGIME PRISIONAL - Pena fixada com critério e corretamente - Reincidência do réu que inviabiliza a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas - Bis in idem não caracterizado, pois o aumento na segunda etapa e a impossibilidade de aplicação do privilégio na terceira fase são efeitos distintos decorrentes do mesmo instituto - Inviável, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, por força do disposto nos artigos 44, incisos I e II, e 77, caput, e inciso I, ambos do CP - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Recurso desprovido." (TJSP - Apelação 0003941-43.2015.8.26.0127 - 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Nelson Fonseca Junior - j. 14/09/2017) -g.n.

Ressalto que não é cabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, porquanto o tempo de prisão provisória do réu não é suficiente para progressão de regime.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas do réu.

Por fim, em relação ao pedido do Ministério Público de decretação de perda dos bens apreendidos, é caso de deferimento.

Quanto à quantia apreendida em poder do acusado (R\$ 330,00), o conjunto probatório revelou que é decorrente do tráfico, não só em razão das circunstâncias de sua apreensão (estava na posse do réu junto com as drogas logo após ele ter sido flagrado em atitude típica do comércio ilegal de entorpecentes), mas também porque não comprovada a origem lícita.

Assim, com fundamento no artigo 63, "caput" da Lei 11.343/06, necessário o decreto de seu perdimento em favor da União.

No tocante à motocicleta, as provas supra analisadas demonstraram que foi utilizada como instrumento para o transporte das drogas destinadas ao tráfico, de modo que pode ser ela confiscada e também decretado seu perdimento em favor da União, consoante o disposto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, não se exigindo, nesses casos, habitualidade, nem mesmo que o veículo esteja preparado especificamente para o transporte da droga, conforme tese fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 647 da Repercussão Geral: "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal" (RE nº 638.491/PR. Relator Min. Luiz Fux, Dje. 23/08/2017).

No mesmo sentido há diversos julgados do E. TJSP:

"Apelação. Tráfico de drogas. Recursos da acusação e da Defesa. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Pena. Causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Reconhecimento da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas. Aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas na fração de 2/3. Possibilidade. Substituição da pena privativa de liberdade. Possibilidade. Regime inicial aberto mantido. Perdimento dos bens e valores. Mantido perdimento do veículo e do dinheiro. Instrumento e produto do crime. Restituição somente do telefone celular. Recursos parcialmente providos". (TJSP -Apelação Criminal 1500705-22.2019.8.26.0627. Órgão Julgador: 2ª

Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Luiz Fernando Vaggione - j. 07/04/2021) - g.n.

“Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença absolutória Recurso Ministerial, buscando a condenação do réu nos termos da denúncia. Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante delito – Apreensão de 186 porções de cocaína (peso aprox. de 271 gramas) – Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos entre si, e em relação àqueles prestados perante a Autoridade Policial – Descrição detalhada da prática da traficância pelo acusado – Versão do réu que não restou comprovada nos autos – Condenação como medida de rigor. Dosimetria da pena – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal – Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes – Na terceira fase, ausentes causas modificativas. Fixação de regime inicial fechado, único compatível com o delito em tela, diante da alta gravidade e reprovabilidade da conduta do réu, em concreto – Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque falta amparo legal, e porque as circunstâncias também não recomendariam a substituição – Tratamento incompatível com os objetivos da Lei de Drogas. Perdimento de bem em favor da União – Veículo utilizado para a prática da traficância de drogas. Recurso Ministerial provido para condenação do réu, nos termos da denúncia. Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente” (TJSP - Apelação Criminal 1500365-60.2019.8.26.0536. Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Ely Amioka - j. 07/04/2021) - g.n.

O C. STJ também já se pronunciou no mesmo sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. TRANSNACIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não se trata de julgamento virtual. A hipótese é de julgamento telepresencial, que segue os mesmos comandos normativos do julgamento presencial. O Agravo Regimental não comporta, na esfera penal, sustentação oral nem requer intimação prévia, consoante o Regimento Interno do STJ (arts. 159 e 258). Pedido de adiamento indeferido.

2. Não se pode falar em cerceamento de defesa no julgamento de origem, uma vez que houve a intimação dos patronos acerca do julgamento realizado e, além disso, para garantir a defesa dos acusados, foram nomeados dois defensores dativos para a sessão.

2. A Corte a quo, em decisão devidamente motivada, com base na análise no vasto conjunto de provas dos autos, entendeu que ficaram comprovadas, de forma indene de dúvidas, as práticas delitivas pelos acusados, mantendo a condenação deles pelos delitos dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, bem como a transnacionalidade do crime.

Assim, concluir pela absolvição dos acusados e pela nacionalidade do crime, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). Assim, mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

4. No presente caso, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da quantidade da droga apreendida (FATO III - apreensão de 5,472kg de skunk e 1,789kg de haxixe) para fixar a pena-base dos acusados, pelo delito de tráfico, 1 ano acima do mínimo legalmente previsto, e, para o crime de associação para o tráfico, em 8 meses, o que se mostra proporcional e razoável.

5. A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. Assim, havendo as instâncias de origem concluído pela utilização do veículo para os fins de tráfico de entorpecentes e, por conseguinte, determinado sua expropriação, não há como esta Corte Superior concluir em sentido contrário, porquanto demandaria a imersão vertical no acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via processual eleita. 6. Agravo regimental não provido". (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1866666/SC. QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - j. 15/09/2020) - g.n.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e:

1) CONDENO o réu LEYNILDO CHRISTIAN PEREIRA DA SILVA a cumprir cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

2) DECRETO o PERDIMENTO em favor da União do dinheiro e da motocicleta apreendidos.

Conforme acima exposto, o réu é reincidente específico, o que indica real possibilidade de reiteração criminosa, demonstrando, de forma concreta, sua maior periculosidade e total impossibilidade da vida em sociedade.

Assim, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual é necessária para garantia da ordem pública e fica, assim, mantida.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra preso, servindo-se a presente de ofício.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

P.R.I.C.

Piracicaba, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA